



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/58/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן-בלום**

התובעת:

**אסנת אזרזר
באמצעות ב"כ עו"ד מזרחי אלון**

נגד

הנתבעים:

1. **וולמן שרה**
2. **בוסקילה יהודית**
3. **שלח רוני – ניתן פס"ד ביום 18.6.20**

פסק דין בעניינן של נתבעות 1 ו-2

תביעה לאכיפת פסק דין מיום 27.11.2013 שבו ניתן תוקף להסכמת הצדדים בהליך קודם שהתנהל ביניהם, בתיק 168/13 לפני המפקחת על רישום מקרקעין חיפה (להלן – **פסק הדין או הסכם הפשרה**). בפסק הדין נקבעו זכויות השימוש של בעלי הדירות ברכוש המשותף,

הצדדים והרקע עובדתי

1. מדובר בבית משותף המורכב ממבנה אחד בן שתי קומות, הנמצא ברחוב מונטיפיורי 3 בחיפה, וידוע כגוש 12315 חלקה 3 (להלן – **הבית או הבית המשותף**).
2. התובעת מתגוררת בקומת הקרקע (ת"ח 2) ומעליה דירת הנתבעת 2 (ת"ח 4). בצדו השני של הבית דירת הנתבע 3 (ת"ח 1) ומעליה דירתה של נתבעת 1 (ת"ח 3). בשנת 2018 רכש נתבע 3 את דירתו מהגב' אייזנברג ציפורה, שהיא צד להסכם הפשרה שעומד במרכז ההליך.
3. הרכוש המשותף של הבית כולל חצר בשטח 780 מטר לערך ושטח גג כלוא מתחת לקומת רעפים ששטחו כ-160 מטר. לטענת הנתבעות, במהלך שנות ה-90 ועד לשנת 2012, מועד רכישת נתבעת 2 את דירתה, הייתה חצר הבית המשותף בשימושה הבלעדי של התובעת, לאחר השתלטותה על החצר המשותפת, ללא הסכמת יתר בעלי הדירות. החל משנת 2011, המועד שבו רכשה נתבעת 1



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/58/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את דירתה, התגלעו מחלוקות בין התובעת לנתבעות שבמרכזן טענות התובעת נגד השימוש הייחודי שעושות הנתבעות בגג הבית המשותף, ומנגד, טענות הנתבעות נגד השימוש הייחודי שעושה התובעת בחצר הבית המשותף.

4. בעקבות סכסוך זה הוגשו תביעות הדדיות ע"י הצדדים, שכאמור הסתיימו בהסכם פשרה שהצדדים לו הם מצד אחד, התובעת כאן; ומצד שני, הנתבעות 1-2 כאן וכן הגב' ציפורה אייזנברג, אשר בנעליה כאמור, נכנס נתבע 3.

בפסק הדין נקבע כדלקמן:

- ..."
1. מוסכם על הצדדים כי התובעת תוכל לעשות שימוש בחלל המצוי מתחת למפלס דירתה המקורית מבלי שחלל זה יסכן את המבנה הקונסטרוקטיבי של הבית המשותף.
 2. התובעות שכנגד תוכלנה לעשות שימוש בחלל שבעליית הגג (במרווח שבין גג הבטון שמעל דירותיהן וחלל שמתחת לגג הרעפים להלן: "עליית הגג") כולל הכשרת עליית הגג כחדרי מגורים הצמודים לדירותיהם, העמדת גרם מדרגות עליה לעליית הגג ופתיחת חלון בעליית הגג. ככל שיידרש היתר מעיריית חיפה יסכימו כל הצדדים לחתום על הסכמה למתן היתר להכשרת עליית הגג כחדרי מגורים להרחבת הדירות העליונות.
 3. כל הדיירים יוכלו למקם את דודי השמש שלהם על גג הרעפים ודודי שמש המצויים בעליית הגג יועתקו ויועקנו על גג הרעפים על חשבון בעליהם.
 4. הצדדים נותנים הסכמתם לתוספת בניה וממ"דים לדירות הבית כאשר הבניה והממ"דים שייבנו ימוקמו מצידי הבית המשותף כל פי תכנון אדריכלי ובאופן שלא יפריעו את הגישה לדירות הדיירים בבית המשותף ו/או יתנו פתרון חלופי מוסכם לכניסה לדירה שמעל ולא יפגע בכניסה לדירות בצד השני.
 5. לאחר שייבנו ממ"דים לדירות באגף בו מצויה דירת התובעת בבית המשותף ותיפטר בעיית המיגון של הדיירים תהא רשאית התובעת לעשות שימוש בלעדי במקלט המצוי מתחת לדירתה וכן תהיה זכאית לעשות שימוש במדרגות המובילות למקלט כמדרגות המובילות לדירתה בלבד.
 6. כל החצר סביב הבית המשותף שלא נבנתה עליה תוספת בנייה שייכת לכל הדיירים.
 7. על אף האמור בסעיף 6 שלעיל מוסכם בזאת כי הגדר והשער שהקימה הנתבעת שכנגד ציפורה אייזנברג ושתחם את השטח המשותף שסמוך לדירתה ויזוז על ידי התובעת שכנגד מס' 1, הגב' וולמן שרה, למרכז החצר במקום שיוסכם על ידן ובלבד שמקום השער והתקנתו, לא יגרמו למפגע ו/או מטרד המונע גישה חופשית של הנתבעת שכנגד מס' 3 לדירתה.
 8. למעט הגדר הנ"ל לא ימוקמו כל גדרות בחצר הבית המשותף אלא בהסכמת כל הדיירים, על אף האמור לעיל, התובעת שהסירה את השער המוביל לדירת התובעת (בוסקילה)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/58/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מתחייבת להשיב את שער הכניסה מברזל בתוך 30 יום
ממועד מתן תוקף של פסק דין להסכם זה.
"...**

5. בעקבות הפרות ההסכם על ידי הנתבעים, הגישה התובעת תביעתה לפניי, שבה היא עותרת לאכיפת הוראות פסק הדין על הנתבעים.
6. הנתבעות 1-2 הגישו כתבי הגנה, וביום 18.6.2020 התקיימה ישיבת קדם משפט. בדיון זה ניתן לבקשת נתבע 3 פסד דין חלקי לטובת התובעת על כל הסעדים שנתבעו על-ידה. בדיון ניתנה לנתבעות רשות לתקן את כתבי הגנתן (ראו להלן).
7. לאחר שהוגשו כתבי ההגנה מטעם הנתבעות, התקיים ביקור במקום ע"י המפקח הקודם, לאחריו הודיעו הצדדים שהם מקבלים את הצעת המפקח שיוגשו סיכומיהם בכתב, לאחריהם יינתן פסק-דין.
8. התיק הועבר לטיפול בעקבות מינויו של המפקח הקודם לשיפוט בערכאה אחרת. בהתאם לסעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 ראיתי להמשיך לדון בהליך מהשלב שאליו הגיע. ביום 30.5.21 ערכתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ועתה נותר לתת פסק דין על סמך סיכומי הצדדים והחומר המונח בתיק. משניתן פסק דין בעניינו של נתבע 3, יתייחס פסק הדין שלהלן לנתבעות 1-2, שייקראו להלן – **הנתבעות**.

טענות התובעת

9. בכתב התביעה טענה התובעת כי הנתבעות הפרו את הוראות פסק הדין.
10. נטען שנתבעת 2 פירקה משטח "דק" שהיה בנוי בשטח הגינה שהיה בשימושה הבלעדי של התובעת מכוח הסכם הפשרה (להלן – **שטח הגינה הייעודי**), וגידרה חלק משטח הגינה הייעודי לטובת שימושה הפרטי.
11. עוד נטען כי הנתבעות סירבו לאפשר לתובעת לעשות שימוש בחלל המצוי מתחת למפלס דירתה, בהתאם לסעיף 1 לפסק הדין, בטענה שחלל זה אמור לשמש את כל בעלי הדירות לצורך הקמת מחסנים לשימושם הפרטי. נוסף על כך, טענה התובעת כי הנתבעים משתהים בבניית ממ"דים לדירותיהם, ובכך מונעים מהתובעת את מימוש זכותה במקלט, עליה הוסכם בסעיף 5 לפסק הדין.

טענות הנתבעות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/58/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. כל אחת מהנתבעות הגישה כתב הגנה בנפרד, אם כי מדובר בנוסח כמעט אחיד בשני כתבי ההגנה, למעט עניינים בודדים (ראה להלן).
13. הנתבעות טענו לניסוח שגוי של סעיף 1 להסכם הפרשה, הנוקט בלשון עתיד, ומתייחס לזכות שימוש עתידית של התובעת, שעה שלתובעת כבר הייתה קיימת זכות שימוש בפועל, וכוונת הצדדים על-פי ההסכם הייתה לתת הכשר לשימוש ייחודי שממילא נעשה ע"י התובעת במרתף ובמקלט, נכון למועד כריתת ההסכם. מעבר לכך נטען שלא הוקנו לתובעת זכויות בנייה עתידיות בפסק הדין.
14. כאמור, בישיבת קדם משפט שהתקיימה ביום 18.6.2020 ניתנה לנתבעות רשות להגיש כתבי הגנה מתוקנים, משלא נכללה בכתבי הגנתן התייחסות לטענת התובעת בדבר זכותה לשימוש ייחודי בשטח הגינה הייעודי, כפי שנקבע בפסק הדין.
15. כתבי הגנה מתוקנים הוגש ביום 7.7.2020. בעקבות טענת התובעת כי בכתבי ההגנה המתוקנים הרחיבו הנתבעות את טיעוניהן מעבר לרשות שניתנה להן (נושא השימוש בגינה), ולנוכח בקשת התובעת להורות על מחיקת כתבי ההגנה או סעיפים מסוימים הכלולים בהם, ניתנה ביום 14.9.20 החלטה המורה שאין לראות בכתבי הגנה ככאלו, אלא כסיכומים מטעם הנתבעות (הגם שבאותו מועד לא ניתן צו להגשת סיכומים). נקבע שהתובעת תוכל להתייחס לסיכומים אלו במסגרת סיכומיה, ובפסק הדין שיינתן בסוף ההליך, תיבחן טענת התובעת להרחבת חזית. לשם הנוחות, ייקראו להלן כתבי ההגנה המתוקנים בשם זה.

כתבי ההגנה המתוקנים

16. נוסח כתבי ההגנה המתוקנים שהגישו הנתבעות זהה, ונטען בהם כי בנוגע לסעיף 1 לפסק הדין הקובע כי התובעת **"תוכל לעשות שימוש בחלל המצוי מתחת למפלס דירתה המקורית..."** אין הכוונה לבנייה עתידית אלא לאפשרות שניתנה לתובעת לעשות לגליזציה לחדר המרתף שבנתה מתחת לדירתה, ששטחו אינו מוצמד לדירתה על פי נסח הטאבו.
17. אשר לסעיף 2 לפסק-הדין הקובע את זכותן של הנתבעות לעשות שימוש בחלל שבעליית הגג ולהכשירו לחדר מגורים הצמוד לדירותיהן, טענו הנתבעות שסעיף זה אינו ישים, היות שנתבע 3 לא היה צד להסכם הפרשה, ולכן ללא הסכמתו, אינן רשאיות לעשות שימוש בלעדי בעליית הגג. לטענת הנתבעות, מטעם זה, רשאית התובעת לעשות שימוש סביר בגג הבית המשותף, כמו יתר הדיירים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/58/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. אשר לסעיפים 4 ו-5 לפסק הדין הקובעים את זכותה של התובעת לעשות שימוש בלעדדי במקלט שמתחת לדירתה לאחר ששאר בעלי הדירות יבנו ממ"דים בדירותיהם, נטען כי נתבע 3 בונה ממ"ד לדירתו, וגם נתבעת 1 הגישה בקשת היתר לבניית ממ"ד. לגבי נתבעת 2 נטען שאין ביכולתה של זו לבנות ממ"ד, ולכן לתובעת אין זכות לעשות שימוש ייחודי במקלט כל עוד לנתבעת 2 אין ממ"ד. לצד זאת, טענו התובעות שאין ממש בטענת התובעת למניעות לעשות שימוש במקלט, שכן בדירתה ישנו גרם מדרגות המוביל לחדר המרתף הנמצא מתחת למפלס דירתה, חדר שנבנה ע"י התובעת ללא היתר בנייה.
19. בנוגע לשימוש שמבקשת התובעת לעשות בשטח הגינה הייעודי, טוענות התובעות שלאור סעיפים 6-7 לפסק הדין הקובעים כי חצר הבית המשותף, שלא נבנתה עליה תוספת בנייה שייכת לכל הדיירים, מנועה התובעת לעשות שימוש בגינה, המהווה חלק מהרכוש המשותף.
20. אשר לטענת התובעת כי נתבעת 2 פירקה משטח דק שהיה בנוי על שטח הגינה הייעודי, נטען כי פעולת פירוק ה"דק" נעשתה ע"י התובעת עצמה, בעקבות הסכם חלוקת שימוש בינה לבין נתבעת 2 לפיו רשאית הנתבעת 2 לעשות שימוש בחלקו העליון של שטח הגינה הייעודית. נטען כי שטח הגינה הייעודי, מהווה חלק מהשטח המשותף וכי נתבעת 2 עושה שימוש בחלקה העליון של הגינה (ליד מדרגות הכניסה לחצר), מאז רכשה את הדירה בשנת 2012.
21. נוסף על האמור, בכתבי ההגנה המתוקנים טענו הנתבעות להפרות פסק הדין ע"י התובעת, בסירובה להשתתף בהכשרת חנייה לבית המשותף כפי שנקבע בס' 10 לפסק הדין, בהתנגדותה לפרויקט לפי תמ"א 38, באי הסדרת הבנייה שבוצעה במפלס שמתחת לדירתה ובתוספות בנייה נוספות שבנתה בדירתה ללא היתר.

דיון והכרעה

22. כל אחד מהצדדים סומך טענותיו על פסק הדין, והמחלוקת שלפניי סבה סביב פרשנותו של פסק הדין בשלושה עניינים:

א. האם לתובעת זכות לבנות במפלס שמתחת לדירתה;



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/58/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- ב. האם יש לחייב את התובעות לקדם את בניית הממ"דים בסמוך לדירותיהן על-מנת שתוכל התובעת לממש את זכותה לעשות שימוש ייחודי במקלט הסמוך לדירתה.
- ג. האם זכאית התובעת לעשות שימוש ייחודי בשטח הגינה הייעודי;

23. כלל הוא, כי חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין; ככל שאומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו. היה ולא ניתן להתחקות אחר אומד דעתם הסובייקטיבי של הצדדים, יש לבחון את תכליתו האובייקטיבית של החוזה, המושפעת בין היתר מעקרון תום הלב, משיקולי היגיון, מיעילות עסקית ומשכל ישר (ראו: דנ"א 2045/05 מגדלי הירקות – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד סא(2) 1 (2006); ע"א 8239/06 אברון נ' פלדה (נבו, 21.12.2008)). אין לייחס לחוזה פרשנות שאינה מתיישבת עם לשונו וחזקה היא, שפרשנות החוזה תואמת את המשמעות הפשוטה העולה מקריאת לשון החוזה (דנ"א 8100/19 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל (נבו, 19.4.2020)). במלאכת פרשנות החוזה, אין לייחס לחוזה פרשנות שאינה מתיישבת עם לשונו, וחזקה היא, שפרשנות החוזה תואמת את המשמעות הפשוטה העולה מקריאת לשון החוזה (דנ"א 8100/19 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ (נבו, 19.4.2020); ע"א 702/80 גלפנשטיין נ' אברהם פ"ד לז(4) 113; ע"א 8080/16 עמודי שחף בע"מ נ' פינקל (נבו, 8.8.2018)).

בהתאם לכללים אלו נפנה לבחון את הוראות פסק הדין.

א. האם מונעות הנתבעות את מימוש זכותה של התובעת לבנות מתחת לדירתה?

24. כאמור, טוענת התובעת כי השתהותן של הנתבעות מבניית ממ"דים לדירותיהן, אינה מאפשרת לה לבנות בחלל שמתחת לדירתה, ובכך נשללת ממנה זכותה על פי ההסכם, לעשות שימוש ייחודי במקלט שמתחת לדירתה.
25. לצורך בחינת טענה זו, יש להכריע תחילה במחלוקת אחרת בין הצדדים, שעניינה בשאלה, האם פסק הדין קובע את זכותה של התובעת לבנות בכל השטח שמתחת לדירתה, או שמדובר רק בשימוש בחדר המרתף שבנתה התובעת ובמקלט, שממילא נעשה בו שימוש ייחודי ע"י התובעת, מזה שנים רבות, כטענת הנתבעות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/58/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- האם לתובעת זכות שימוש ייחודי מתחת לדירתה, ואם כן, מה היא כוללת?
26. בסעיף 1 לפסק הדין נקבע: **"מוסכם על הצדדים כי התובעת תוכל לעשות שימוש בחלל המצוי מתחת למפלס דירתה המקורית מבלי שחלל זה יסכן את המבנה הקונסטרוקטיבי של הבית המשותף."**
27. מביקורי במקום ביום 30.5.21 עולה כי החלל שמתחת למפלס דירת התובעת כולל חדר אליו יורדים מדירתה של התובעת, וכן מקלט ושטח נוסף, אליהם ישנה גישה מחוץ לדירת הבית.
28. מסיכומי הנתבעות עולה לכאורה כי הנתבעות זנחו טענתן זו. וכך נכתב בסיכומים: **"הסכם הפשרה מתיר לתובעת להשתמש בחדר המרתף אשר הכשירה מתחת לביתה ונבנה על שטחו של המקלט המשותף ללא היתרים, שימוש זה או/ו שימוש נוסף מצריך אישור של מהנדס"**. מדברים אלו ניתן להבין כי הנתבעות מאשרות את זכותה התובעת לביצוע עבודות בנייה בשטח שמתחת לדירת התובעת, בכפוף לאישור מהנדס, ובכך מסכימות למתן הסעד הנוגע לשימוש ייחודי במפלס שמתחת לדירתה. למרות זאת, ולמען הזהירות, אבחן את טענות הנתבעות בעניין זה לגופו של עניין.
29. ייאמר כבר עתה, שקיבלתי את עמדת התובעת, כי בפסק הדין נקבעה זכותה של התובעת בכל שטח החלל המצוי תחת דירתה, והשימוש שהותר בהסכם כולל בנייה בשטח זה. הדברים עולים מבחינת לשון ההסכם הקובעת זכות שימוש **"בחלל המצוי מתחת למפלס דירתה המקורית"**. **"בחלל המצוי"** – משמעו בכל החלל ולא בחלקו. סביר להניח שאם כוונת הצדדים הייתה לעשיית שימוש רק בחלק הבנוי או בחלק מסוים אחר מהחלל שמתחת לדירתה, היה הדבר מצוין באופן מפורש בהסכם.
30. בעניין זה טענו הנתבעות בכתבי הגנתן (המקוריים והמתוקנים) ל"ניסוח שגוי" של הסכם הפשרה, בנקיטתו בלשון עתיד, שעה שלטענתן, כוונת הצדדים בעת חתימת ההסכם הייתה לעגן את השימוש שממילא נעשה ע"י התובעת, נכון לאותה העת, בחלל שמתחת לדירתה בחלק שכבר נבנה על ידה; אך לא לאפשר לתובעת בנייה נוספת. גם בדיון שהתקיים ביום 18.6.20 חזרו הנתבעות על הדברים (פרוטוקול עמ' 3, שו' 2-3, שו' 7-8, 13-15, עמ' 29-31, שו' 33-34)
31. כאמור, שוכנעתי כי לתובעת ניתנה זכות שימוש ייחודי בכל המפלס שמתחת לדירתה, ובכלל זה, זכות בנייה בשטח זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/58/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. בחינת לשון ההסכם מעלה כי התניית השימוש הבלעדי של התובעת בשטח שמתחת למפלס דירתה כוללת התניית השימוש בהבטחת יציבותו של הבית המשותף, וכלשון סעיף 2 להסכם: **"...התובעת תוכל לעשות שימוש בחלל המצוי מתחת למפלס דירתה המקורית מבלי שחלל זה יסכן את המבנה הקונסטרוקטיבי של הבית המשותף"**. הסעיף משמיענו כי זכות השימוש שעוגנה בהסכם אינה מוגבלת רק לשימוש בחלק הבנוי כטענת הנתבעות; אלא כוללת גם בנייה, שכן אם מדובר בשימוש בחלק הבנוי, מה טעם מצאו הצדדים לכלול תניה המתייחסת למניעת סיכון למבנה הקונסטרוקטיבי של הבית המשותף? אם כטענת הנתבעות מדובר בבנייה שכבר הושלמה, ולא עומדת על הפרק בנייה נוספת, סביר שלא הייתה נכללת תניה בנוגע להבטחת תקינותו הקונסטרוקטיבית של המבנה. למען הסר ספק, בשום שלב לא עלתה טענת הנתבעות לבנייה אחרת שביצעה התובעת שיצרה סיכון קונסטרוקטיבי, שניתן היה אולי לייחס לה את הצורך בהוספת תניה זו.

33. יש לזכור שמדובר בהסכם פשרה שהוגש לאישור המפקחת ע"י הצדדים שהיו מיוצגים כולם ע"י עורכי דין; יש להניח שהוראותיו ותניותיו נקבעו ביישוב הדעת, לאחר שקילת מכלול השיקולים הרלבנטיים, וסביר בעיניי שהסעיף מגבש את הסכמת הצדדים בנוגע לבנייה עתידית ואין מדובר בטעות בניסוח, כטענת הנתבעות.

34. יצוין כי המסקנה אליה הגעתי, שפסק הדין מקנה לתובעת זכות בנייה עתידית בחלל שמתחת למפלס דירתה המקורית מקבלת תימוכין נוספים ביתר תניות ההסכם. הסעיף העוקב לסעיף הנ"ל, מתייחס לתמורה שמקבלות הנתבעות אל מול ויתורן על הזכות לבנות בשטח שמתחת לדירת התובעת, והוא פותח במילים: **"התובעות שכנגד תוכלנה לעשות שימוש בחלל שעליית הגג..."**.

35. לא זו אף זו. מבחינת לשון סעיפים 2-5 לפסק הדין ניתן לקבוע כי בהסכם הפשרה נקבע הסדר סימטרי, שבו כל צד מקבל זכויות מסוימות תוך ויתור על זכויות אחרות לטובת הצד שכנגד. במקרה שלפניי, התובעת קיבלה זכות לבנות בחלל שמתחת לדירתה תוך ויתור על הזכות לבנות בעליית הגג, ואילו הנתבעות קיבלו זכות לבנות בשטח הגג תמורת ויתורן על המפלס שמתחת לדירת התובעת. שטח עליית הגג הוא כ-160 מטר (קרי, 80 מטר לכל נתבעת), וגם שטח החלל שמתחת לדירת התובעת כבן 80 מטרים (ראו: הבקשה להיתר בנייה ואישור הקונסטרוקטור שצורפו לכתב התביעה). מעבר לשטחים אלו, ניתנה לכל אחד מבעלי הדירות זכות לבנות תוספת ממ"ד לדירתו, כפי שנקבע בסעיף 4 לפסק הדין.

36. בשולי הדברים אתייחס לטענת התובעת בדבר הרחבת הנתבעות את חזית הגג. בהחלטה שניתנה בדיון מיום 18.6.20 ניתנה לנתבעות רשות לתקן את כתבי הגנתן. טענת התובעת כי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/58/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ההיתר לתיקון כתב ההגנה יוחד לנושא השימוש בגינה, אינה מוצאת ביטוייה בהחלטה האמורה, אך ראיתי לקבלה, משלא נסתרה ע"י הנתבעות. כפי שפורט לעיל, טענות הנתבעות בעניין זכות התובעת לבנות מתחת לדירתה, נדחו לגופו של עניין. הפרת ההחלטה בעניין זה תקבל ביטוייה בפסיקת ההוצאות.

37. יש לקבוע אם כן, כי בפסק הדין ניתנה לתובעת זכות שימוש ייחודית בחלל שמתחת למפלס דירתה, הכוללת הסכמה לבנות בשטח זה.

ב. האם הפרו הנתבעות את חובתן לבנות ממ"דים?

38. לטענת התובעת, הנתבעות לא פעלו בהתאם להסכם המחייבם בבניית ממ"ד לדירותיהן, ובכך נפגעת זכותה של התובעת לבנות על גבי המפלס שמתחת לדירתה.

39. נפנה לבחון את לשון תניות ההסכם הרלבנטיות לעניין זה:

4. הצדדים נותנים הסכמתם לתוספת בניה וממ"דים לדירות הבית כאשר הבניה והממ"דים שייבנו ימוקמו מצידי הבית המשותף כל פי תכנון אדריכלי ובאופן שלא יפריע את הגישה לדירות הדיירים בבית המשותף ו/או יתנו פתרון חלופי מוסכם לכניסה לדירה שמעל ולא יפגע בכניסה לדירות בצד השני.

5. לאחר שייבנו ממ"דים לדירות באגף בו מצויה דירת התובעת בבית המשותף ותיפטר בעיית המיגון של הדיירים תהא רשאית התובעת לעשות שימוש בלעדי במקלט המצוי מתחת לדירתה וכן תהיה זכאית לעשות שימוש במדרגות המובילות למקלט כמדרגות המובילות לדירתה בלבד.

40. סעיף 4 קובע את זכותם של כל בעלי הדירות לבנות תוספת ממ"ד לדירותיהם. סעיף 5 להסכם קובע שהתובעת רשאית לממש את זכותה לעשות שימוש ייחודי במקלט המצוי במפלס מתחת לדירתה (זכות שהוקנתה לה בסעיף 1 להסכם), לאחר שהנתבעים יבנו ממ"ד לדירותיהם. הרציונל מאחורי הדברים מצוין בהסכם: קיומו של ממ"ד בדירות הנתבעים, ייתן מענה מיגון חלופי למקלט, במקום המקלט שיעבור לשימושה הייחודי של התובעת.

41. נטען כי נתבעים 1-3 החלו בפעולות כאלו ואחרות לקראת בנייתו של ממ"ד, בניגוד להם טענה נתבעת 2 שאין בכוונתה לבנות ממ"ד וכל עוד אין ממ"ד לדירתה, לא תהא התובעת רשאית לעשות שימוש ייחודי במקלט (פרוטוקול מיום 18.6.21, עמ' 3 שו' 3-2).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/58/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

42. עולה השאלה, האם ניתן לראות בלשון סעיף 5 הקובע כי "**לאחר שייבנו ממ"דים...תהא רשאית התובעת לעשות שימוש בלעדי במקלט...**" כסעיף המטיל חיוב על נתבעת 2 לבנות ממ"ד?

43. מעיון בסעיף 5 להסכם, ומבחינתו על רקע יתר הוראותיו של הסכם הפרשה, לא ניתן להגיע לתוצאה המבוקשת ע"י התובעת. כאמור, במסגרת ההסכם עוגנה חלוקת השימוש ברכוש המשותף עליה הסכימו הצדדים, כך שצד אחד ויתר על זכותו לעשות שימוש בחלק מסוים של הרכוש המשותף ומנגד, זכה לעשות שימוש ייחודי בחלקו האחר. כן מקנה ההסכם לצדדים זכות לבנות תוספת ממ"ד לדירותיהם: "**הצדדים נותנים הסכמתם לתוספת בנייה וממ"דים לדירות הבית**". כך ולא יותר. לשון ההסכם אינה נושאת אופי של חיוב בהקשר של בניית הממ"דים, כפי שלשון ההסכם הקובעת את זכותן של הנתבעות לבנות בחלל שבעליית הגג, אינה בגדר חיוב.

44. כל שנקבע בהסכם הוא זכות הצדדים לבנות ממ"דים ובנייה אחרת, בהתאם לרצונם ולשיקול דעתם. ביחס לתובעת, ישנה התייחסות נוספת בהסכם, הקובעת את זכותה של התובעת לעשות שימוש ייחודי במקלט לאחר שייבנה ממ"ד לדירת נתבעת 2. מדובר בתניה המגבילה את זכותה של התובעת, במובן זה שזכותה לשימוש ייחודי במקלט קמה רק לאחר שייבנה ממ"ד לדירת נתבעת 2, ואין למצוא בה מקור לחיובה של נתבעת 2, כפי שטוענת התובעת. תוצאה פרשנית המטילה חיוב על נתבעת 2 לבנות ממ"ד, אינה משתמעת מלשון ההסכם ומנסיבות העניין.

45. איני מקבלת את טענת התובעת כי השימוש בתיבה "לאחר שייבנו ממ"דים" מייצר ודאות שאלו אכן ייבנו ולכן נדרש להשלים את החסר ולקבוע זמן סביר לביצוע תניה זו ע"י נתבעת 2. ככל שביקשה התובעת ליצור ודאות לבניית הממ"דים ע"י הנתבעים, סביר היה שהדבר היה מעוגן בתניות ההסכם. לא שוכנעתי שמדובר בחסר שנוצר כתוצאה מהסחת דעת של הצדדים אלא מדובר בביטוי לרצון הצדדים שלא תוטל עליהם חובה לבנות ממ"ד או כל תוספת בנייה אחרת. משלא ננקטה לשון חיוב ולא נקבעו פרטים לרבות מועד לביצוע הבנייה, יש לראות בהעדרם של אלו כאי השתכללות הסכם בנוגע לחובת בניית ממ"ד או כל בנייה אחרת, ולא כחסר שיש להשלימו. כאמור, ההסכם נערך ע"י באי כוח הצדדים, ויש לצאת מנקודת הנחה שהסעיף מגבש את רצון הצדדים, ואין מדובר בטעות או בהשמטה מקרית.

46. לעניין זה, ראיתי להביא ציטוט מהדברים הבאים:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/58/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"לא בכל מקרה שבו החוזה שותק בעניין מסוים, קיים חסר באותו עניין. עלינו להבחין בין שתיקה לחסר...רק אחד מהקולות הללו הוא קול החסר...הבנה מוטעית, המסיקה חסר במקום שהוא אינו קיים, מובילה לכך שבית המשפט קובע תניות חוזיות לצדדים בלא שהוסמך לכך. זוהי תוצאה חמורה שיש להימנע ממנה. היא פוגעת באוטונומיה של הרצון הפרטי של הצדדים לחוזה" (א' ברק פרשנות במשפט: פרשנות החוזה (תשס"א) 136-137).

"...מכאן שטרם שיושלם החסר מן ההסכם הנדון, יש לברר תחילה, מתוך ההסכם או מתוך הנסיבות, כי אכן קיימת "לאקונה", שרק אז ניתן להשלים את החלל בנורמה חוזית חדשה, המבוססת על הוראת דין (חקוקה או הלכתית). שאם אין מדובר ב"חסר", שהצדדים להסכם הסיחו דעתם ממנו בעת ההתקשרות, פשיטא הוא, שאין בסמכותו של בית המשפט "לעשות חוזה חדש, שונה במהותו, בתכנו או בהיקפו ובתחולתו מזה שעשו הצדדים עצמם" (ע"א 528/86 פולגת תעשיות בע"מ נ' עיזבון המנוח יעקב בלכר ז"ל, פ"ד מד(3) 821, 826 (1990)).

47. סיכומם של דברים, מלשון ההסכם בכללותו ומנסיבות העניין יש לקבוע שלא הוחלה על הנתבעות חובה לבנות ממ"ד לדירתן, ואין מדובר בחסר שיש להשלים אלא באי השתכללות הסכם מחייב בין הצדדים בנקודה זו. לנוכח התוצאה אליה הגעתי, לא ראיתי מקום להתייחס ליתר הטענות בסיכומי התובעת בעניין זה.

ג. האם לתובעת זכות לשימוש ייחודי בשטח הגינה, והאם זו הופרה?

48. בכתב התביעה מבקשת התובעת להורות על זכותה הייחודית בשטח הגינה הייעודי. "שטח הגינה הייעודי" מגדיר על פי התובעת, חלק מהגינה המשותפת ששטחו כ-126 מ"ר, הנמצא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/58/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משמאל לדירתה, בחלק המתחיל סמוך למדרגות הכניסה הראשית לבית המשותף, בהתאם לסימון על תשריט הבית שצורף כנספח 2 לכתב התביעה.

49. כפי שנאמר, כתבי ההגנה המקוריים לא כללו התייחסות לסעד שנתבע בעניין השימוש בגינה, ובהמשך הגישו הנתבעות כתבי הגנה מתוקנים שבהם נטען כי לתובעת לא הוקנתה זכות ייחודית כלשהי בגינה המשותפת.

50. נפנה לבחון את הסכם הפשרה, המסדיר בסעיפים 6-8 את נושא השימוש בשטח הגינה :
..."

6. כל החצר סביב הבית המשותף שלא נבנתה עליה תוספת בנייה שייכת לכל הדיירים.

7. על אף האמור בסעיף 6 שלעיל מוסכם כי הגדר והשער שהקימה הנתבעת שכנגד ציפורה איזנברג ושתחם את השטח המשותף שסמוך לדירתה ושיזוז על ידי התובעת שכנגד מס' 1, הגב' וולמן שרה, למרכז החצר במקום שיוסכם על ידן ובלבד שמקום השער והתקנתו, לא יגרמו למפגע ו/או מטרד המונע גישה חופשית של הנתבעת שכנגד מס' 3 לדירתה.

8. למעט הגדור הנ"ל לא ימוקמו כל גדרות בחצר הבית המשותף אלא בהסכמת כל הדיירים, על אף האמור לעיל, התובעת שהסירה את השער המוביל לדירת התובעת (בוסקילה) מתחייבת להשיב את שער הכניסה מברזל בתוך 30 יום ממועד מתן תוקף של פסק דין להסכם זה.

"...

51. הסכם הפשרה משמיענו באופן ברור, שהחצר שמסביב לבית המשותף, שלא נבנתה עליו תוספת בנייה כלשהי, שייכת לכל הדירות למעט החלק הסמוך לדירות נתבעים 1 ו-3 (בתביעה כאן), המגודר בגדר ובשער. למעט אלו, אין למקם גדרות בחצר הבית המשותף.

52. לא קיבלתי את טענת התובעת כי יש לראות בהגבהת הגינה, יישורה ותחיתמה באמצעות "טרסה" כ"תוספת בנייה" על שטח החצר, כמשמעותה של "בנייה" על פי ההסכם. מהראיות שצירפה התובעת לבקשתה מיום 10.8.20, מבקשת התובעת ללמד על בניית טרסה וקיר בשטח החצר הסמוכה לדירתה. אין בידי לקבוע על סמך ראיות אלו, מהן אותן פעולות "בנייה" שביצעה התובעת, משלא ניתן להסיק מאותן חשבוניות וקבלות שצורפו, כי אלו כולן שימשו לטובת הבנייה הנטענת, בוודאי שלא מונחת לפני הוכחה להוצאה בגובה 70,000 ₪ (כנטען לראשונה בסיכומי התשובה של התובעת). גם בהנחה שאכן נבנתה טרסה (וקיר תומך) ע"י התובעת, הרי שפרשנות התובעת שמדובר בתוספת בנייה, אינה מתיישבת עם לשונו הפשוטה של ההסכם בדבר תוספת של בנייה על שטח החצר. טענת התובעת ששטח הגינה הייעודי ניתן לה לשימושה הבלעדי, אף אינה מתיישבת עם לשון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/58/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סעיף 8 האוסרת על קיומן של גדרות בחצר הבית. לו הייתה כוונת הצדדים להותיר את שטח הגינה הייעודי לשימוש ייחודי של התובעת, היו הגדרות והתוספות שהקימה התובעת ובאמצעותן תחמה את שטח הגינה הייעודי, מוחרגות מההסכם, כפי שנעשה ביחס לגדר הסמוכה לדירתה של איזנברג (בסעיף 7 להסכם). יושם לב לטענת התובעת בסעיף 88 לסיכומיה שפעולותיה בגינה אינן מינוריות אלא מדובר בפעולות בנייה משמעותיות שתייחסו את הגינה באופן ברור – בהסכם אין ביטוי לחלק התוחם את גינתה של התובעת, כפי שצוין בהסכם במקומות אותם ביקשו הצדדים להחריג. ביחס לתובעת הוזכר עניין הגדרות במקום אחד בהסכם: בסעיף 8 המתייחס לחובתה של התובעת להשיב למקומו את שער הכניסה מברזל, המוביל לדירת נתבעת 2.

53. יש לזכור שהשימוש הייחודי של התובעת בשטח הגינה היה הגורם העיקרי להתגלעות הסכסוך בין הצדדים בשנת 2011, ועמד במרכז המחלוקת בהליך הקודם, שבמסגרתו גובש הסכם הפשרה. התובעת הייתה מיוצגת בהליך, וסביר להניח שלו היה מוסכם על הצדדים שהתובעת תמשיך לעשות שימוש ייחודי בשטח הגינה הייעודי - שטח נכבד כבן 126 מ"ר - היה הדבר מקבל ביטוי מפורש בהסכם.

54. יש לשאול, מה קרה ממועד חתימת ההסכם ועד להגשת התביעה שלפניי? מדוע לא הגישה התובעת תביעתה לאכיפת פסק הדין קודם לכן? לעובדה שלא הוגשה תביעה בעניין הפרת זכותה לכאורה של התובעת לשימוש ייחודי בגינה, אלא בחלוף 6 שנים ויותר ממועד גיבוש ההסכם יש חשיבות בבירור אומד דעת הצדדים. יושם לב, שבכתב התביעה התובעת אינה מציינת מועד או אירוע מסוים שבו הופרה לכאורה זכותה הייחודית בגינה (בסעיף 21.1 לכתב התביעה מצוין שנתבעת 2 פירקה משטח "דק" בגודל כ-16 מ"ר כדוגמה לטענה בדבר סיכול זכויות התובעת על פי ההסכם; אלא שבסעיף 14 לתביעה צוין שמדובר במעשה שקדם להליך המשפטי משנת 2013).

55. מהחומר שלפניי נראה כי בשנים שחלפו ממועד פסק הדין ועד לאחרונה, נהגו הצדדים על פי הסכם הפשרה, ולא נעשה ע"י התובעת שימוש ייחודי בגינה. נקודת המפנה הייתה, בעת שביקשה התובעת מהצדדים לחתום על הסכמתם לעבודות הבנייה שביקשה לבצע מתחת לדירתה. משנתקלה בסירובן של הנתבעות, שכן אלו חזרו בהן מהסכמותיהן לוותר על זכותן במפלס שמתחת לדירת התובעת, חזרה בה גם התובעת מהסכמתה בנושא הגינה. הדברים עולים בין היתר מפרוטוקול הדיון מיום 18.6.20: **"גב' שפיר: היא טוענת שיש לה זכות בגינה בגלל שאנחנו הפרנו את ההסכם הפשרה. החלל מתחת לבית נמצא בשימוש שלה. אנחנו לא מסכימים שהיא תעשה שימוש בגינה"** (עמ' 3 שו' 10; ראו גם עמ' 4 לפרוטוקול שו' 1-6).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/58/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

56. יצוין כי מביקורי במקום ניתן היה להתרשם שמדובר בשטח גינה משמעותי ולא ברצועת גינה צנועה. מצאתי את שטח הגינה הייעודי מחולק ע"י גדר במבוק, באופן שבו החלק שמתחיל מגרם מדרגות הכניסה לבית המשותף ועד לגדר הבמבוק נמצא בשימושה של נתבעת 2, ובחלק שמעבר לגדר עושה התובעת שימוש (ראו גם התרשמותו של המפקח הקודם מביקורו במקום, כפי שמוצאת ביטוייה בפרוטוקול שערך ביום 29.6.20, אותו אני מאמצת במלואו). מטענות הצדדים בעת הביקור במקום וכפי שעולה מפרוטוקול הדיון מיום 18.6.20 (עמ' 4, שו' 4 שו' 5-7) נראה שחלוקת השימוש והצבת גדר הבמבוק נעשתה בהסכמת התובעת והנתבעת 2 לאחר מתן פסק הדין, וזו יצוין כפופה להסכמת יתר בעלי הדירות. כאמור, התרשמתי כי התובעת "שברה את הכלים" וטענה לזכותה להשתמש בכל שטח הגינה הייעודי, בעקבות סירובן של הנתבעות לחתום על הסכמתן לבנייה שביקשה התובעת לבצע מתחת לדירתה.

57. עוד יצוין כי לא שוכנעתי בטענת התובעת להיגיון עסקי-כלכלי ביישום פסק הדין בעניין הגינה לפי פרשנותה. בסעיף 25 לסיכומיה טענה התובעת ש"שווי הממ"ד" (שקיבלו הנתבעים – ע"מ) ושווי המקלט (שקיבלה התובעת – ע"מ) מתאזנים" ואילו שטח המרתף והגינה יחד שווים פחות משטח עליית הגג שניתן לנתבעות. מעבר לכך שלא הובאו ראיות להוכחת הטענה, הרי שטענה זו מתעלמת מהעובדה שגם התובעת קיבלה זכות לבניית ממ"ד.

58. **סיכומם של דברים, לא הוכחה לפניי טענת התובעת כי הוקנתה לה זכות לשימוש ייחודי בחצר הבית המשותף.**

סיכום

59. לאור הנימוקים שהובאו לעיל, אני קובעת כדלקמן:

- א. הסכם הפשרה אינו קובע את זכותה של התובעת לשימוש ייחודי בשטח הגינה המשותף, ולכן התביעה למתן סעדים בעניין זה נדחת.
- ב. התובעת זכאית לעשות שימוש בחלל המצוי מתחת למפלס דירתה, לרבות בנייה בשטח האמור, בתנאי שלא יהיה בעבודות אלו לגרוע מזכותן ומיכולתן של הנתבעות לעשות שימוש במקלט הנמצא במפלס זה, כמקום מחסה, זאת עד שתיתר בעיית המיגון של כל בעלי הדירות בבית, בהתאם לתניה הקבועה בסעיף 5.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/58/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ג. הסכם הפשרה אינו מטיל חיוב על הצדדים לבניית ממ"דים לדירותיהם, ולכן התביעה לסעד בעניין זה נדחית.

ד. טענות הנתבעות בכתבי הגנתן ובסיכומיהן (בסעיף 27) נדחות, משלא מונחת לפניי תביעה בעניין סעדים אלו.

60. לנוכח התוצאה אליה הגעתי, ראיתי לחייב כל אחת מהנתבעות בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪. בסכום זה נתתי משקל לדחיית חלק ניכר מן הסעדים שנתבעו ולניהול ההליך ע"י הנתבעות בסטייה מסדרי הדין. כמו כן ניתן ביטוי לכך שלא התנהל הליך הוכחות ובכך נחסך זמן שיפוט יקר.

מזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן בלשכתי ביום ד' אלול, 12 באוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.

**עינת מידן-בלום
מפקחת על רישום מקרקעין**